

刑法
No.315

H21-15

(配点: 3)

月	日
月	日

次のアからオまでの各事例における甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、自己が所有し、その旨登記されている家屋を乙に売却して引き渡し、その売買代金を受領した後、乙への所有権移転登記が完了する前に、当該家屋に丙を権利者とする抵当権を設定し、その旨の登記をした。甲は、乙に当該家屋を売却して引き渡している以上、当該家屋は「自己の占有する」物とはいえないので、甲には乙を被害者とする横領罪は成立しない。
- イ. 甲は、自己の実父である乙から、乙の友人である丙所有の刀剣を保管するように委託され、当該刀剣を保管していたが、乙及び丙に無断で、当該刀剣を丁に売却した。甲には横領罪が成立するが、甲は乙の「直系血族」であるので、刑が免除される。
- ウ. 甲は、自己が所有し、その旨登記されている土地について、乙を権利者とする抵当権を設定した後、その旨の登記が完了する前に、当該土地に丙を権利者とする抵当権を設定し、その旨の登記をした。乙には抵当権があるにすぎず、当該土地は「他人の物」とはいえないので、甲には乙を被害者とする横領罪は成立しない。
- エ. 甲は、家庭裁判所から甲の孫乙の未成年後見人に選任され、後見の事務として乙の預金通帳及び印鑑を預かっていたが、これらを使用して、ほしいままに乙の預金口座から現金500万円を引き出し、自己の遊興のために費消した。甲には業務上横領罪が成立するが、甲は乙の「直系血族」であるので、刑が免除される。
- オ. 甲は、A会社の代表取締役であるが、権限がないのに、A会社が所有し、その旨登記されている土地について、甲を債務者、乙を権利者とする抵当権を設定し、その旨の登記を完了した後、さらに、権限がないのに、当該土地を丙に売却してその旨の登記を完了した。当該土地に抵当権を設定してその旨の登記をした時点で、甲には業務上横領罪が成立するので、当該土地を丙に売却してその旨の登記を完了した行為についてA会社を被害者とする業務上横領罪は成立しない。

No.315	横領の罪						正答率
H21-15	正解	ア 2	イ 2	ウ 1	エ 2	オ 2	65%

ア 誤っている

最判昭 30.12.26。横領罪（252 条 1 項）の客体は、自己の占有する他人の物であるところ、本記述では「占有」の意義が問題となる。この点、判例は、不動産売買において、所有権移転登記が未了のときには、売主はいまだ当該不動産の占有を有するものとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、横領罪における占有は事実的支配のみならず法律的支配を含むということを挙げている。本記述では、家屋の登記名義人甲に、当該家屋の占有が認められる一方、売買契約の成立によって、当該家屋の所有権は乙に移転している（民法 176 条）。そして、横領行為とは自己の占有する他人の物について不法領得の意思を実現する一切の行為を指すことから（大判大 6.7.14）、本記述における抵当権設定行為も横領行為に当たる。よって、甲は自己の占有する乙の物を横領したことになり、甲には乙に対する横領罪が成立する。

イ 誤っている

大判昭 6.11.17。横領罪には、親族相盗例が準用される（255 条・244 条）、本記述では、親族関係を必要とする相手方の範囲が問題となる。この点、判例は、親族相盗例が適用されるには、親族関係が犯人と委託者の間のみならず、犯人と所有者の間にも存在しなければならないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、親族相盗例の趣旨は、親族間の財産秩序は親族内部において維持すべきであるということを挙げている。本記述では、甲が刀剣を売却した行為につき横領罪が成立する。そして、甲は、委託者である乙とは親族関係にあるものの、所有者である丙と親族関係にないため、親族相盗例は適用されない。その結果、甲の刑は免除されない。

ウ 正しい

最判昭 31.12.7（百選Ⅱ70 事件）。横領罪の客体は自己の占有する他人の物であるところ、本記述では、二重抵当により「他人の物」を横領したといえるかが問題となる。この点、判例は、二重抵当により抵当権を侵害した場合、背任罪（247 条）の成立を認めるものの、横領罪の成立は認めていない。これは、自己所有の不動産に抵当権を設定しただけでは、いまだ当該土地は「他人の物」とはいえず、所有権の侵害が認められないためである。本記述においても、甲所有の土地には乙の抵当権が設定されているにすぎず、二重抵当により乙の所有権が侵害されたとはいえないことから、甲に横領罪は成立しない。

エ 誤っている

最決平 20.2.18（百選Ⅱ35 事件）。横領罪には、親族相盗例が準用される（255 条・244 条）、本記述では、未成年後見人が、親族関係を有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合にも親族相盗例が準用されるかが問題となる。この点、本記述と類似の事案において、判例は、親族相盗例の準用を否定している。その理由として、判例は、親族相盗例の趣旨につき「親族間の一定の財産犯罪については、国家が刑罰権の行使を差し控え、親族間の自律にゆだねる方が望ましいという政策的な考慮に基づく」と述べた上で、「未成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって」「上記のような趣旨で定められた刑法 244 条 1 項を準用して刑法上の処罰を免れるものと解する余地はない」としている。

オ 誤っている

最大判平 15.4.23 (百選Ⅱ69 事件)。本記述では、自己が占有する他人の物に関して、一度横領罪が成立した後、同一物について更に不法処分を行うことが、別途横領罪を成立させるかが問題となる。この点、本記述と類似の事案において、判例は、「委託を受けて他人の不動産を占有する者が、これにはしきままに抵当権を設定してその旨の登記を了した後においても、その不動産は他人の物であり、受託者がこれを占有していることに変わりはなく、」「先行の抵当権設定行為が存在することは、後行の所有権移転行為について犯罪の成立自体を妨げる事情にはならない」とし、後行行為について横領罪の成立を認めている。